

1501572-71.2021.8.26.0618

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Magistrado: João Carlos Germano

Comarca: Taubaté

Foro: Foro de Taubaté

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/02/2022

... manutenção e venda de armamento utilizado no tráfico de drogas. Perguntado sobre o revólver calibre 22, de fabricação regular, disse que este estava sobre a mesa e foi o próprio réu quem o mostrou. Ademais, no quarto, que era uma espécie de oficina, havia moldes e maquinários usados para a fabricação das peças. Sobre o procedimento, não soube explicar com detalhes, todavia, se ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Taubaté

Foro de Taubaté

3ª Vara Criminal

Praça Monsenhor Silva Barros - s/nº, Fórum Criminal

CEP: 12020-070 - Taubaté - SP

Telefone: (12) 2124-9113 - E-mail: taubate3cr@tjsp.jus.br

1501572-71.2021.8.26.0618 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501572-71.2021.8.26.0618

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Rafael Andrade da Silva

Réu Preso

Juiz de Direito: João Carlos Germano

Vistos.

Rafael Andrade da Silva foi denunciado pelo Ministério Público porque, no dia 11 de novembro de 2021, por volta das 21h04min, na Rua Um, 11, Residencial Sérgio Lucchiari, Bairro São Gonçalo, nesta cidade e comarca de Taubaté, adquiriu, recebeu, tinha em depósito, desmontou, montou, remontou, adulterou, vendeu, expôs à venda, ou de qualquer forma utilizou, em proveito próprio, no exercício de atividade comercial, 1 revólver, marca Rossi, calibre 22, com 2 cartuchos íntegros; 1 arma de fogo artesanal, calibre 38, com 1 cartucho íntegro; 1 arma de fogo artesanal, com 3 cartuchos íntegros; sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo se apurou, em patrulhamento de rotina, os policiais visualizaram o réu no interior da residência observando a viatura em movimento. Ao ser notado, fechou a janela, atitude que despertou a atenção dos policiais. Em seguida, os milicianos estacionaram a viatura próximo a residência, desligaram os sinais luminosos e sonoros e permaneceram no local para averiguar possível ilícito. Na sequência, o réu deixou a residência, momento em que foi abordado. Questionado, confessou que

estava guardando uma arma de fogo e autorizou o ingresso na residência.

Em vistoria no imóvel, os policiais localizaram as armas supramencionadas, bem como 2 coletes balísticos, 2 moldes para confecção de arma de fogo artesanal e 1 coldre.

Busca, assim, a condenação do réu como incurso no artigo 17, §1º, da Lei 10.826/03.

A denúncia foi recebida às fls. 66/67.

Citado (fls.156), o réu apresentou resposta escrita a acusação às fls. 73/75.

Designou-se audiência, ocasião em que foram ouvidas as testemunhas Thiago Maciel Alves, Pedro Paulo Campos de Palma e João Pedro Câmara de Freitas, procedeu-se ao interrogatório do réu Rafael Andrade da Silva, colhendo-se alegações finais do Ministério Público e da Defesa.

O Ministério Público postulou a procedência do pedido, alegando que a autoria e a materialidade do delito foram devidamente comprovadas pelas provas existentes nos autos. Afirmou que a negativa de autoria é mendaz, uma vez que não encontra respaldo no acervo probatório reunido, tratando-se de inútil tentativa de livrar-se da grave imputação penal. Ademais, alegou que a história contada para justificar a posse dos objetos ilícitos é inverossímil e destituída de lastro probatório. Justificou que, caso o réu estivesse apenas guardando, os objetos não estariam espalhados em diversos cômodos do imóvel, bem como não saberia discorrer aos agentes públicos a forma de confecção das armas de maneira tão detalhada. Além disso, destacou que, nos termos do artigo 156, do Código de Processo Penal, é atribuição da Defesa comprovar os fatos alegados, sob pena de não serem consideradas válidas as argumentações lançadas, fato que não ocorreu no caso concreto, no qual verificou a deficiência para demonstrar a versão apresentada. Em contrapartida, mencionou que os agentes públicos descreveram de maneira detalhada e coerente as diligências encetadas que culminaram na localização e apreensão dos ilícitos na residência do réu. Ressaltou, ainda, que não há dúvida em relação à autorização concedida para o ingresso no imóvel, fato corroborado pelo próprio réu na Delegacia, o que corresponde às declarações prestadas pelos policiais militares. Salientou que as declarações dos agentes públicos merecem credibilidade e servem como fator determinante para a formação de convicção do julgador, desde que seus relatos estejam em sintonia com os demais elementos de provas. Por outro lado, ressaltou que a testemunha arrolada pela defesa não colaborou para a elucidação dos fatos, pois não presenciou o delito e não acompanhou a diligência policial. Por fim, declarou que o laudo pericial encartado a fls. 96/101 comprovou a materialidade delitativa, uma vez que apontou a eficácia das munições e a existência de dois moldes para a confecção de arma de fogo, assim como diversas peças características de arma de fogo com utilização para fabricação artesanal. Embora não houve comprovação da eficácia das armas, tendo em vista que estavam em fase de reparo ou confecção, estas corroboraram a atividade de comércio ilegal de arma de fogo praticada pelo réu no interior da residência. Nesse contexto, requereu a condenação do réu nos exatos termos da denúncia. No tocante à dosimetria da pena, na primeira fase, pediu que a pena-base seja fixada no mínimo legal. Na segunda fase, há a incidência da agravante da reincidência. Não vislumbrou causa de aumento e diminuição de pena. Por fim, considerando que o réu praticou crime grave, é reincidente, o que revela culpabilidade exacerbada, denotando personalidade voltada para a prática reiterada de crimes, pleiteou a fixação de regime de cumprimento mais severo, sendo recomendável o fechado, único condizente e eficaz para inibi-lo de praticar novas infrações.

A Defesa, por sua vez, requereu, preliminarmente, a nulidade pela quebra da cadeia de custódia. Manifestou que o exame de corpo de delito é imprescindível nos casos em que a infração deixa vestígios, como no caso concreto, todavia, este necessita, independente da espécie, do suporte material sobre o qual se aplicarão metodologias

e conhecimentos das ciências naturais. Portanto, anotou que se faz necessário a existência de fontes confiáveis e lícitas uma vez que a contaminação da fonte contaminará também o resultado do estudo, interferindo negativamente na credibilidade do exame. Diante dos depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela prisão, ressaltou que houve nítida quebra da cadeia de custódia, haja vista que além do local não ter sido periciado, um dos milicianos alega que supostamente o Delegado de Polícia teria dispensado a perícia no local. Assim sendo, afirmou que a imputação do delito previsto no artigo 17, § 1º, da Lei nº 10.826/03, se encontra tão somente baseada no depoimento dos policiais, uma vez que que em nenhum momento foi produzido outro meio de prova hábil. A eventual quebra da cadeia de custódia gera, portanto, irrefutável ilicitude da prova a que se refere aquele conjunto de atos, motivo pelo qual postulou o reconhecimento da ilicitude e determinação de consequente desentranhamento dos autos, bem como determinar a extensão da ilicitude quanto a eventuais provas derivadas. Subsidiariamente, solicitou a desclassificação do delito previsto no artigo 17, § 1º, da Lei nº 10.826/03, para o artigo 12 do mesmo diploma legal. Ressaltou que o acervo probatório se consubstancia unicamente no depoimento dos policiais militares, no sentido de que o réu teria confessado informalmente a destinação daquele material ilícito, qual seja, atividade comercial/ industrial, todavia, isto não se demonstrou alicerçado em nenhum outro elemento que atestasse a veracidade desses depoimentos trazidos, haja vista a inexistência de qualquer liame subjetivo para com outrem (conversa sobre negociação da venda ou do concerto de armamento), assim como, diante da ausência da confirmação por parte do réu, que apesar de confirmar a prática delitiva em juízo, não aduziu nenhuma palavra no sentido de comercialização ou manutenção de qualquer armamento. Outrossim, mencionou que o réu não fora flagrado manuseando/fabricando nenhum armamento, o que se constatou foi a apreensão daquele material ilícito em sua posse, tão somente. Em concordância, o laudo pericial afirma que a única arma de fogo apta a disparar encontrada na sacola, possui registro e, diante da confissão do réu no sentido de que estava guardando aquele material, torna-se de rigor a desclassificação para o artigo 12, do mesmo diploma legal. Além do mais, justificou que se ele de fato estivesse nessa prática, teria anotações, como controle de armamento, lista de clientes, ou até mesmo conversas comprometedoras em seu aparelho celular, todavia, isso não existiu. Frisou, ainda, que o depoimento policial é meio de prova e, como qualquer outro, deve estar em harmonia com as demais provas constantes nos autos, situação não verificada no caso. Em eventual condenação, considerando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, na primeira fase, postulou que a pena-base seja fixada em seu mínimo legal. Na segunda fase, diante da confissão espontânea e integral pelo réu, que contribuiu em muito para o deslinde da ação penal, pleiteou o reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, em seu grau máximo, caso entenda pela majoração na primeira etapa. Esclareceu que, apesar do réu ser reincidente, deve haver a compensação com a confissão espontânea. Não vislumbrou causas de aumento e diminuição de pena. Por fim, quanto ao regime prisional, diante do quantum de pena aplicado, pediu a fixação do regime inicial aberto. Na remota hipótese pela não concessão, com base na Súmula 269, do STJ, requereu a fixação do regime inicial semiaberto.

É o relatório.

Decido.

Cuida-se de ação penal pública incondicionada por meio da qual o Ministério Público requereu a condenação do réu como incurso no artigo 17, §1º, da Lei 10.826/03.

A Defesa suscitou preliminar de quebra da cadeia de custódia, afirmando nula a prova.

O pedido, contudo, não comporta acolhimento.

Aferindo-se a situação fática que permeou a prisão do réu, não se vislumbra a hipótese de quebra da cadeia de custódia, porque observadas as prescrições legais nesse ponto.

Com efeito, todo o material apreendido foi devidamente lacrado e, posteriormente, periciado, atendidos todos os requisitos que exige a lei.

A despeito de afirmar o contrário a Defesa, não era necessária a perícia do local, mas sim apenas dos objetos encontrados e que, como declinado, foram recolhidos pelos policiais e devidamente lacrados.

Dessa forma, não se vislumbra qualquer ilegalidade da conduta dos policiais, especialmente no que tange à cadeia de custódia, devidamente atendida.

Não havendo outras questões preliminares a se enfrentar, importa afirmar que as condições da ação estão presentes, assim como os pressupostos processuais, o que rende ensejo a apreciação do mérito.

É o caso de acolhimento do pedido condenatório.

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls.1), boletim de ocorrência (fls.2/6), termos de depoimento (fls.7/8), interrogatório (fls.9) e auto de apreensão (fls.14/15), laudos periciais (fls. 96/101 e 129/134) e demais depoimentos colhidos.

Com relação a autoria, melhor sorte não assiste o acusado, em razão da robusta prova atribuindo a ele a prática do crime de comércio ilegal de arma de fogo.

A testemunha Thiago Maciel Alves, ouvida em juízo, relatou que receberam uma denúncia anônima de um transeunte, o qual informou que um indivíduo estava produzindo armas de fogo no endereço em questão. Em patrulhamento no local, visualizaram o momento em que o réu percebeu a presença policial, pela janela, e entrou rapidamente. Diante do comportamento suspeito, procederam à abordagem na frente da residência. Questionado sobre bens ilícitos, negou a princípio e afirmou que possuía apenas armas de brinquedo. Franqueada a entrada, o réu lhes mostrou um quarto, que era uma espécie de oficina, e possuía diversas ferramentas e partes de armamento. Ato contínuo, localizaram em uma das bancadas um revólver prateado. Perguntado, o réu confessou que era dele, e que sua família não tinha qualquer participação. Continuaram as buscas, devido às muitas partes de armamento, localizando, em outro quarto, diversos tipos de moldes para confecção de armas. Na ocasião, ele justificou que eram apenas armas artesanais e que não estavam aptas a efetuar disparos. Sobre o processo, narrou que compactava o material, derretia o metal fundido e colocava sobre um molde de isopor, montando as peças dos revólveres. No local, foram apreendidos um revólver calibre 22, um revólver artesanal calibre 38 e peças de um terceiro revólver, sem tambor. Todo o material foi recolhido e apresentado na Delegacia para realização dos laudos. Não o conhecia por abordagens anteriores.

A testemunha Pedro Paulo Campos de Palma, ouvida em juízo, narrou que receberam uma denúncia anônima, de que um cidadão possuía arma de fogo na residência. Ressaltou que a denúncia não mencionava características do indivíduo. Dessa forma, procederam ao patrulhamento pelo local e, em um dia no período noturno, o réu percebeu a presença policial e entrou rapidamente no imóvel, demonstrando atitude suspeita. Desconfiados, o abordaram na porta da residência e questionaram sobre qualquer posse ilícita, mas ele negou. Efetuada revista pessoal, nada foi encontrado. Nesse momento, contou que possuía uma arma dentro da casa e autorizou a entrada dos policiais, para mostrá-los o objeto. Além do revólver, foram

localizados diversos moldes de armamento artesanal. Indagado, disse que fabricava as armas artesanais para algumas pessoas do bairro, fazendo manutenção e venda de armamento utilizado no tráfico de drogas. Perguntado sobre o revólver calibre 22, de fabricação regular, disse que este estava sobre a mesa e foi o próprio réu quem o mostrou. Ademais, no quarto, que era uma espécie de oficina, havia moldes e maquinários usados para a fabricação das peças. Sobre o procedimento, não soube explicar com detalhes, todavia, se recorda dele ter mencionado que utilizava terra e um cano de aço. Afirmou que no momento da abordagem, estava a esposa do réu, a qual não foi arrolada como testemunha, sendo que ele confessou a posse total dos objetos. Alegou que não o conhecia anteriormente. Disse que o Delegado dispensou a perícia no local.

A testemunha João Pedro Câmara de Freitas, ouvida em juízo, informou que conhece o réu há um ano, do condomínio em que moram. Declarou que ele é tatuador e já fez tatuagens com ele, sendo que nunca viu a mencionada oficina. Afirmou que os apartamentos do condomínio são pequenos e, dessa forma, não caberia uma oficina. Disse que no bairro em que moram nunca ouviu rumores de que ele fizesse armas ou estivesse vinculado ao tráfico de drogas. Relatou que, no dia em que a polícia apareceu, estava presente, mas não acompanhou a revista feita por eles. Perguntado, disse que não tem conhecimento sobre os objetos apreendidos.

O réu Rafael Andrade da Silva, interrogado em juízo, asseverou que tem conhecimento da acusação e negou que seja verdadeira. Justificou que tem um estúdio de tatuagem no condomínio há muitos anos e um de seus clientes pediu que ele guardasse os objetos em sua residência, oferecendo-lhe a quantia de R\$ 150,00 por noite. Relatou que os armamentos deveriam ficar em sua posse por alguns dias, até que o indivíduo encontrasse outro lugar para armazená-los. Questionado, disse que não poderia identificá-lo, por receio de represália à sua família. Com relação à abordagem, disse que recebeu os itens em um saco preto e tinha acabado de colocá-los sobre a mesa para ver do que se tratavam, quando os policiais entraram no local, sem sua autorização, e o acusaram de porte ilegal. Na ocasião, estavam sobre a mesa dois coletes, revólveres e pedaços de armamento, os quais ele não soube dar detalhes. Alegou que não conhecia os policiais anteriormente. Indagado, disse que, no momento, devido à pressão, inventou a história de que tinha envolvimento com a usinagem de armas, mas negou a veracidade dos fatos. Afirmou que condomínio em que mora, em razão do tamanho dos apartamentos, não poderia ter uma oficina, conforme mencionado, e tinha apenas utensílios usados para as tatuagens no cômodo. Disse ser casado, sem filhos e mora com a esposa; trabalha como tatuador, com renda média de R\$ 700,00 por quinzena; tem outro processo por roubo.

Bem provadas a autoria e a materialidade.

Dispõe o artigo 17, §1.º, do Estatuto do Armamento:

“Art. 17. Adquirir, alugar, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, adulterar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão, de 6 (seis) a 12 (doze) anos, e multa. (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

§ 1º Equipara-se à atividade comercial ou industrial, para efeito deste artigo, qualquer forma de prestação de serviços, fabricação ou comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercido em residência.”

Daquilo que se tem no processo, verifica-se a existência de provas robustas da conduta do réu, que encontra subsunção no disposto no artigo acima elencado.

Com efeito, os policiais que se encarregaram da prisão foram assertivos e firmes ao

dizer que ao passar pelo local dos fatos observaram o réu em atitude suspeita, ante denúncia feita anteriormente por transeunte. Depois de aguardar um tempo, sem chamar atenção, quando ele deixou o imóvel foi abordado e prontamente disse que tinha armamento em sua casa, franqueando a entrada dos policiais.

Na casa, ainda consoante o relato dos policiais, o réu mantinha uma espécie de oficina, com moldes, partes de armas, munições e armas, que evidenciavam a confecção de armamento caseiro.

Some-se ao relato dos policiais, a apreensão do material que demonstra, não outra coisa, que o réu tinha em depósito, montava e desmontava, em proveito próprio ou alheio, arma de fogo, no exercício de atividade comercial, sem que tivesse, para tanto, autorização legal.

Não há dúvida que o material apreendido servia ao propósito de fabricação de armas para venda, na forma do §1.º, acima elencado. Isso porque referido parágrafo equipara à atividade comercial qualquer forma de fabricação, inclusive aquela exercida em casa.

No caso em exame, resultou devidamente evidenciado que o réu fabricava armamento em sua casa.

O artigo em pauta não exige que se comprove atos de mercancia. Apenas a fabricação informal em casa já caracteriza o delito, não havendo que se falar em desclassificação.

Nesse sentido a lição de Guilherme Nucci, aduzindo que a atividade informal também é repelida pela norma:

“Atividade comercial ou industrial por equiparação: a preocupação do legislador foi a mesma estampada no art. 180, §2.º, do Código Penal, quando quis atingir o 'comerciante de fundo de quintal', nos casos de desmanche de veículos, no cenário do crime de receptação. Portanto, o disposto no parágrafo único, do art. 17, desta Lei, tem a mesma finalidade. Há quem exerça (a habitualidade preexistente permanece) o comércio ou a indústria em caráter informal, prestando serviços (consertando armas, por exemplo) fabricando (construindo acessórios ou munições, em outro exemplo) ou comercializando (comprando, vendendo e alugando armas de fogo), como ilustração, em sua própria casa, sem a aparência de atividade comercial ou industrial regular. Aliás, na verdade, cuida-se, de fato, de atividade irregular, vale dizer, ilegal.” (Leis penais e processuais penais comentadas – 8.ª Ed., vol 2, RJ, Forense, 2014, p. 38).

Verifica-se que a alegação do réu de que guardava os itens para outra pessoa, cuidou de versão apresentada com o escopo de minorar sua responsabilidade, pois sem amparo em nenhum elemento de prova constante dos autos, a par de ir de encontro aos fatos apurados.

Isso porque, consoante relato dos policiais, o material se encontrava em uma espécie de oficina, e estavam espalhados pelo apartamento, evidenciando o seu manuseio e não simples guarda, pois se estivesse apenas guardando para outra pessoa e tivesse acabado de receber o material como afirmado, obviamente que o material estaria acondicionado em um único local.

Além disso, há contradição em seu interrogatório. Verifica-se que em um primeiro momento afirmou que estava com os materiais há 15 minutos, pois tinha acabado de receber de um terceiro. Mais ao fim, disse que estava com as coisas há 3 dias.

Acerca da questão, cabe acrescentar que os policiais relataram que o réu confirmou que produzia e repara armas no local, versão condizente com a situação fática

encontrada pelos policiais e com os produtos apreendidos, relato que o réu em juízo confirmou ter feito aos policiais, mas afirmou que inventou tal história por se sentir pressionado.

Assim, o que se evidencia pela prova amealhada é que o relato fornecido ao policiais pelo réu no momento da sua prisão é convincente e encontra amparo nas circunstâncias fáticas constantes dos autos, ao contrário da versão pouco inverossímil apresentada pelo réu em juízo.

Vê-se, nesse contexto, que o réu era, por ocasião dos fatos, imputável e tinha plena consciência do ilícito perpetrado, não havendo excludente de ilicitude ou de culpabilidade que viesse em seu benefício.

A prova nos autos produzida, atenta ao contraditório e à ampla defesa, é segura e não deixa dúvida de que praticou a conduta descrita na denúncia, devendo responder pelo crime em questão.

Afirmada a responsabilidade, passa-se à dosimetria da pena, atendendo-se à disposição do artigo 68, do Código Penal, ao critério trifásico proposto por Nélson Hungria e ao princípio da individualização da pena.

Na detida análise das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, observa-se que a culpabilidade – que consiste na reprovabilidade da conduta – se mostra normal à espécie, nada havendo a se valorar.

O réu não detém maus antecedentes, contudo, é reincidente, o que será valorado no momento apropriado.

Não há nos autos elementos acerca da conduta social.

No que se refere à personalidade do agente - que no entender de Guilherme Nucci é aquela que está vinculada às qualidades morais, às distorções de caráter, à índole do sujeito, que são extraídos de sua forma habitual de ser, agir e reagir (in Individualização da pena, RT, 2005, p. 207) - se mostra negativa.

Isso porque resultou claro que o réu mentiu em Juízo quando alterou a versão dos fatos ocorridos, trazendo exposição falsa acerca de como se passaram os fatos, visando a uma injusta desclassificação. Essa atitude demonstra a distorção de caráter e a ausência de senso moral por parte do réu, que se vale da mentira com o propósito de impor tumulto à instrução processual e, maliciosamente, induzir em erro o julgador, com afronta à dignidade da justiça.

Sobre a questão, oportuno ressaltar que ainda que seja o interrogatório um meio de defesa e de prova, evidente que o réu deva respeitar as limitações impostas pelas regras do processo, especialmente aquelas decorrentes da lealdade, da ética, da boa-fé, não se podendo esquecer que o processo é um instrumento para a realização da Justiça, dotado de uma série de formalidades que, em ultima ratio, são verdadeiras garantias para o réu, como também para a sociedade.

Ora, é forçoso reconhecer que o réu ao mentir deliberadamente extrapola os limites da autodefesa – que não é absoluta – demonstrando torpeza e deslealdade processual, expondo a risco a Justiça que pode, em razão de seu proceder, proferir decisão equivocada e, assim, injusta.

Afigura-se evidente que não se pode tolerar que o réu se valha de engodos, ardis e mentiras visando a escapar de uma justa condenação. O acusado que assim age, frauda a produção de provas e torna o processo uma chicana pessoal e egoísta, revelando sua personalidade dissimulada, amoral, o que justifica a elevação da pena.

Acerca do tema, pertinente o registro da lição de Andrey Borges de Mendonça (Prisão e outras Medidas Cautelares Pessoais, 2011, Método, p. 194): "Parece-nos, assim, que se o juiz constatar que o réu mentiu, poderá considerar tal circunstância no momento da pena. Não é que se esteja estimulando a confessar - até porque para isto já há uma circunstância atenuante genérica -, mas apenas negando que ao juiz e ao Poder Judiciário possa se admitir que o réu venha em juízo e, perante um agente do Estado, possa mentir livremente, como se isto fosse algo normal e aceitável, como se entende atualmente".

O entendimento acima explicitado, ainda que minoritário na jurisprudência, tem sido prestigiado em várias decisões judiciais, cabendo o registro, por todas, de parte do judicioso voto da lavra do Desembargador José Raul Gavião de Almeida, na Apelação 00771651-20.2015, da 6ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, julgada em 30 de novembro de 2017 :

"...Se o réu optar por falar, no interrogatório, deverá medir suas palavras, porque elas poderão ser utilizadas também em seu desfavor. É o que ocorre na hipótese do acusado apresentar versão contrária ao convincente conjunto probatório. Identificado que faltou com a verdade, esse comportamento e o teor da inexatidão podem ser considerados pelo julgador, pois não existe direito à mentira, como não há a correspondente obrigação de ignorar a verdade"

Ainda sobre o tema, se revela oportuno registrar parte do artigo " A mentira do réu como elemento relevante na dosagem da pena", da lavra do Promotor de Justiça do Estado de São Paulo, Dr. Cleber Pereira Defina, que de forma judiciosa analisou o tema:

"...assim como a confissão dos fatos denota aspecto louvável da personalidade do agente, pois atua com boa-fé e consciência social, o inverso também é verdadeiro: a mentira do agente sinaliza aspecto censurável de sua personalidade, pois atua com má-fé e franca ausência de consciência social, constituindo-se, portanto, em dado sensível quando da individualização da pena. O indivíduo que mente à autoridade só pretende beneficiar-se com a própria torpeza, conduz ao indesejável erro judiciário, prejudica o direito das vítimas e mina a justiça. Este cenário ratifica a deformação dos valores carregados pelo acusado pinoquista, repercutindo em necessidade ainda maior de reconstituição da tábua de valores socialmente almejada em relação ao acusado enganador. Ora, se é justo que a postura de lealdade do imputado deve surtir efeito no sentido de diminuir sua reprimenda, porque atrelada a condições favoráveis de sua personalidade, segue-se clarividente que há mesma justiça em extrair efeito no sentido de agravar a reprimenda do réu que ostenta péssima personalidade caracterizada pela insolência de mentir perante as autoridades que colheram sua versão dos fatos, especialmente quando a este acusado lhe foi garantido o direito ao silêncio. Aliás, onde o silêncio for útil, não se justifica a mentira. O mesmo Estado que garante ao processado o direito ao silêncio, a possibilidade de não se autoincriminar, que pode criar recompensas para este falar, como é o caso da atenuante da confissão e do acordo da delação premiada, também deve poder intensificar a reprimenda daquele que ousa falar com o exclusivo propósito de enganar e promover injustiça. O embuste, tanto quanto a lealdade, é vetor a moldar a pena justa, pois ambos dizem respeito à personalidade refletida do agente"http://www.esmp.sp.gov.br/revista_esmp/index.php/RJESMPSP/article/view/148/68).

Em suma, todo acusado tem o sagrado e inafastável direito ao silêncio, que decorre da garantia democrática de que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo (nemo tenetur se detegere ou privilege against self incrimination); contudo, tal direito não pode admitir a interpretação que alguns lhe emprestam de tornar aceitável, ou pior, irrelevante, a conduta comissiva de mentir, que é vil, antiética e contrária aos valores mais mezinhas da sociedade, ao revés, deve o

julgador, por ocasião da individualização da pena, caso constatado que o réu mentiu ao ser interrogado em juízo, fixar a pena-base em patamar superior ao mínimo, amparado na personalidade negativa do acusado, pois evidente a ausência de senso moral, denotando índole desviada e personalidade distorcida, daquele que podendo se calar opta deliberadamente por mentir em juízo.

Não se pode olvidar, ainda, que o réu, desde a promulgação da Lei 11.719/2008, é interrogado após a colheita de todas as provas, inclusive depoimento das testemunhas, de forma que tem plena consciência das provas produzidas e da sua repercussão, mormente em razão da defesa técnica que o assiste, razão pela qual a sua opção pela mentira se mostra ainda mais censurável, cínica e abjeta, pois abre mão do direito ao silêncio, e até mesmo da atenuante da pena da confissão, para tentar induzir em erro o juízo e assim ferir a dignidade da justiça.

A propósito, impende registrar, por relevante, que caso o julgador não aumente a pena do acusado mendaz, "estará incentivando o réu a sempre mentir, afinal, se sua mentira não lhe causa qualquer prejuízo, podendo, inclusive, livrá-lo de uma condenação justa, por que confessar um crime ou mesmo ficar em silêncio? Não punir o acusado mentiroso, aliás, viola o princípio da individualização da pena, pois equipara equivocadamente a situação do réu que fica em silêncio em seu interrogatório, com a do que mente descaradamente, em verdadeira afronta à dignidade da Justiça, pois tem o único propósito de induzir esta em erro, minando, assim, sua credibilidade perante a sociedade" ("A mentira do réu e a Dosimetria da Pena", artigo de autoria do Promotor de Justiça, Dr. André Wagner Melgaço Reis, publicado na rede mundial de computadores, no endereço <http://www.cartaforense.com.br/autor/andre-wagner-melgaço-reis/958>).

Nesse passo, cabe trazer recentíssima decisão proferida pelo voto do i. Desembargador Tetsuzo Namba:

"...demais disso, se eles tinham a opção de confessar ou ficar em silêncio, no momento que se pronunciavam, suas palavras devem ser ponderadas, se mentem, como no caso dos autos, isso não pode ficar sem avaliação valorativa negativa, sob pena de deixar de lado quem, muitas vezes, colabora com a Justiça e diz a verdade, seria o patrocínio indevido da "não verdade", isso mostra o caráter de alguém, flagrado no cometimento de infração penal, não se arrepende, ao contrário, faz de tudo para se livrar das imputações... (TJSP – Apelação Criminal 0001611-29.2018.8.26.0625, 8.^a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, j. 28.11.2019).

Cabe anotar que o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, em julgamento recente, por votação unânime, decidiu no mesmo sentido da tese que ora se adota, trazendo excertos de decisão proferida por este juízo como razão de decidir, como se infere dos autos da Apelação nº 0000129-67.2018.8.26.0618, de relatoria do ilustre Desembargador Roberto Porto:

"Ademais, como bem destacou o Ministério Público a fl. 277 o fato de o réu ter mentido em Juízo, trazendo aos autos fatos absolutamente inverídicos, revela sua personalidade desvirtuada, devendo ser considerado no momento da exasperação da reprimenda. Aliás o Douto Magistrado bem fundamentou a exasperação da pena-base..."

No mesmo sentido já decidiu a Colenda 14^a Câmara de Direito Criminal, por votação unânime nos autos da apelação nº 0000640-36.2016.8.26.0618, de relatoria do ilustre Desembargador Walter da Silva:

"(...) Em relação ao delito previsto no artigo 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/03: Sopesadas as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, a pena base foi bem fixada acima do mínimo legal, fundamentando o douto Magistrado na personalidade negativa do apelante, pois demonstrou perante o Juiz desonestidade e insinceridade, o que revelou a distorção de caráter, e assim a reprimenda foi

tornada definitiva na ausência de outras causas modificadoras."

Ainda sobre a mentira do réu como circunstância desfavorável, com enfoque na personalidade desviada, em voto proferido pela 6.^a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, pela voz do ilustre relator Zorzi Rocha, assentou:

"Dessa forma, se o réu mentir em seu interrogatório, negando a prática do crime por ele cometido, ou explicando o crime ao apresentar uma versão fantasiosa do fato, tudo a fim de se obter uma injusta absolvição, justificado está o aumento de sua pena-base com fundamento na personalidade negativa. Afinal, a insinceridade e a desonestidade demonstradas perante o Juiz – como explanado no item 2 suso exposto – revelam distorção de caráter e ausência de sendo moral por parte do Réu, que se utilizou da mentira – subterfúgio repugnado pela ética e pelo dever de lealdade – com nítido propósito de tumultuar a instrução processual e induzir em erro o julgador, afrontando, assim, a dignidade da Justiça" (TJSP – Apelação Criminal 0001317-32.2017.8.26.0618, j. 3.10.2019).

Não outra a conclusão a que chegou o ilustre Des. Ricardo Sale Júnior, chamando atenção para a correção do decisum que elevou a pena-base pelo fato de haver o réu mentido ao ser interrogado em juízo "fato que evidencia uma personalidade voltada para o crime" (TJSP – Apelação Criminal 0002205-19.2013.8.26.0625, 15.^a Câmara de Direito Criminal, j. em 8.8.2019).

No mesmo sentido o voto da lavra do ilustre Des. Tetsuo Namba, ao aduzir correta a sentença que reconheceu a mentira do réu como personalidade deturpada, justificando-se a elevação da pena na primeira fase da dosimetria. (TJSP – Apelação Criminal 0001091-27.2017.8.26.0618, 8.^a Câmara de Direito Criminal, j. em 5.12.2019).

Também em processo que teve trâmite por esta 3.^a Vara, em sede de apelação (Apelação Criminal nº 0000037-05.2017.8.26.0625), a i. Desembargadora Ivana David, assentiu com a tese ora perfilada, nos termos seguintes, fazendo alusão, em parte, à decisão proferida nos autos do Processo Criminal nº 0003339-30.2014.8.26.0372, 1.^a Vara Judicial de Hortolândia - Juiz de Direito, Luis Mário Mori Domingues j. 21.01.2015.

"E escorreita a majoração praticada, uma vez que ao mentir em juízo, a acusada foi muito além do seu direito ao silêncio, mentindo para a Justiça, tentando se esquivar das consequências dos seus atos, porquanto, "nosso ordenamento jurídico, amparado por tratados internacionais e na linha de todos os demais sistemas penais do mundo garantem ao acusado o direito ao silêncio. Significa dizer que o réu, silenciando-se, não pode ser acusado com base nesse fundamento, isto é, ausente provas contra o réu, ele não pode ser condenado porque ficou em silêncio. Em momento algum o direito ao silêncio confunde-se com direito a mentira. O silêncio é uma conduta passiva, fundada no direito de não produção de prova contra si. A mentira é conduta ativa, é a produção de prova falsa em juízo", demonstrando, com isso, além da má índole, que o crime não constituiu um episódio acidental em sua vida. (Tribunal de Justiça de São Paulo, j. 10.12.2019).

Os motivos do crime são os naturais à espécie, bem como as consequências são ordinárias, sendo, assim, neutras para o fim de fixação da pena.

A vítima é a coletividade, nada havendo, então, a ser valorado.

Nesse passo, na fixação da pena-base, considerando-se a personalidade negativa do réu, impõe-se elevar a pena mínima cominada em 1/6, alçando-a a 7 anos de reclusão e 11 dias-multa.

Na segunda fase, não há circunstâncias atenuantes, presente, contudo, a agravante da reincidência, que faz agravar a pena em 1/6, elevando-a a 8 anos e 2 meses de reclusão, além de 12 dias-multa.

Na terceira fase, não há causa de diminuição ou aumento, fixada definitivamente a pena em 8 anos e 2 meses de reclusão e 12 dias-multa.

O regime inicial de cumprimento, sendo a apenação maior de 8 anos, desfavoráveis as circunstâncias judiciais e reincidente o réu, será o fechado.

Anoto que essa é a posição pacificada no Superior Tribunal de Justiça, que determina o regime fechado ao condenado com circunstâncias judiciais desfavoráveis e reincidente (RECURSO ESPECIAL Nº 1.710.041 - MS).

Ainda, da mesma Corte Superior:

"1- Nos termos do art. 33, §§ 1º, 2º e 3º, do Código Penal, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o julgador deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada, bem como a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do Código Penal). 2 - Constatada a reincidência do paciente e a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, é forçoso reconhecer a possibilidade de manutenção do regime fechado para o cumprimento da pena, não havendo que se falar, na hipótese, em incidência do enunciado 269 da Súmula desta Corte, segundo o qual "É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais". 3 - No caso em análise, embora o quantum da reprimenda (1 ano e 6 meses de reclusão) comporte o regime aberto, a reincidência e as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao paciente impedem, inclusive, a fixação do regime intermediário, sendo adequada a imposição do regime fechado. 4 - Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no HC 407.838/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe de 21/11/2017).

Nos termos do artigo 49, §1.º, do Código Penal, o valor do dia multa será de 1/30 avos do salário mínimo praticado à época do delito, pois ausentes elementos para aferição da capacidade financeira do réu, devendo ser atualizado pelos índices de correção monetária da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo desde aquela data até o efetivo pagamento.

Observo que o réu não preenche os requisitos do artigo 44, do Código Penal, pois é reincidente e as circunstâncias judiciais não indicam ser suficiente a substituição por pena restritiva de direitos.

Também não preenche o réu os requisitos do artigo 77, do Código Penal, especialmente pela reincidência, sendo inviável a suspensão condicional da pena.

Deixo de fixar indenização mínima prevista no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, pois inexistente pedido nos autos, fato que inviabiliza o contraditório e a ampla defesa, bem como se afasta do princípio da congruência.

Mantém-se a prisão, recomendando-se aquela em que se encontra.

É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal que inexistente ilegalidade em vedar ao condenado recorrer em liberdade quando esteve preso cautelarmente durante toda instrução criminal, desde que permaneçam os motivos dessa segregação (STF, HC n. 89824/MS 1ª T. unânime Min. Carlos Ayres Britto DJe 28/8/2008; STF HC n. 114536/MG 2ª T. unânime Rel. Min. Ricardo Lewandowski DJe 4/12/2012; STJ, HC n. 222002/RJ 5ª T. unânime Rel. Min. Laurita Vaz DJe 11/10/2013).

No caso concreto, o réu permaneceu preso cautelarmente durante todo o processo e o retorno ao convívio social, neste momento, é inoportuno. Assim, para que a ordem pública permaneça acautelada, é necessária a manutenção do cárcere.

Além disso é o réu reincidente, mostrando-se imprescindível acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça. A reiteração criminosa evidencia o envolvimento com o mundo do crime, de forma que apenas a prisão preventiva se mostra suficiente para afastar a possibilidade de novas infrações penais.

Nesse contexto, ainda persistem os fundamentos fáticos e jurídicos que ensejaram a segregação cautelar, agora mantida com base em um juízo de certeza da culpa.

Assim, presentes os pressupostos e fundamentos para a decretação da prisão preventiva, a teor do artigo 312 e seguintes do Código de Processo Penal, fica mantida a prisão (artigo 387, §1º, do Código de Processo Penal), negando-se o direito de recorrer em liberdade.

Diante de tal quadro, verificada a necessidade da manutenção da custódia cautelar, resulta cumprido o disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Não há dados suficientes para realização da detração da pena, razão pela qual deixa-se de cumprir o disposto no artigo 387, §2, do Código de Processo Penal, cabendo ao juízo da execução, que detém as informações necessárias, analisar oportunamente eventual direito por conta do período de prisão cautelar, consoante determina o artigo 66, inciso III, alíneas "b" e "c". Nesse sentido: (HC 169.072/SP, relator Ministro Og Fernandes - 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, julgado em 10.6.2010).

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, de acordo com o artigo 804, do Código de Processo Penal.

Posto isso, acolho o pedido formulado na denúncia para o fim de condenar o réu Rafael Andrade da Silva à pena de 8 anos e 2 meses de reclusão, além de 12 dias-multa, como incurso no artigo 17, §1º, da Lei 10.826/03, iniciando-se o cumprimento em regime fechado, recomendando-o à prisão em que se encontra, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, condenando-o, outrossim, ao pagamento das custas no importe de 100 UFESPs, nos termos do artigo 4.º, § 9.º, alínea "a", da Lei estadual 11.608/03.

Após o trânsito em julgado deverá a Serventia levar a efeito as seguintes providências:

- a) intimar o réu para proceder ao recolhimento da pena pecuniária, nos termos do artigo 686, do Código de Processo Penal, assim como ao pagamento da taxa judiciária;
- b) oficiar ao TRE para cumprimento do disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal;
- c) oficiar ao IIRGD comunicando a condenação do réu;
- d) expedir guia de execução penal.

R.P.I.

Taubaté, 1º de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA